

1500232-40.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... da persecução penal, confessou a prática do tráfico, em razão das dificuldades financeiras. Disse que sua esposa Vitória sabia que ele comercializava drogas, mas não participava de nada. Disse que o valor apreendido era proveniente do tráfico. Confirmou ainda que a balança de precisão era utilizada para pesar drogas (fls. 09/10 e 238/239).

A confissão livre e espontânea ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500232-40.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500232-40.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2038444/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 16144437 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI,

456/21/309 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2038444 - DEL.POL.BIRIGUI, 456/21/309 -

DEL.POL.BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIKE DIORDAN JORDÃO COSTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500232-40.2021.8.26.0603 (Controle: 327/2021).

VISTOS.

MIKE DIORDAN JORDÃO COSTA e VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ambos menores de 21 anos, qualificados nos autos, foram presos em flagrante delito, denunciados e viram-se processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, no dia 09 de fevereiro de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Felício Migliorini, nº 837, Residencial Portal da Pérola II, cidade e comarca de Birigui, MIKE DIORDAN JORDÃO COSTA, trazia consigo 130 (cento e trinta) eppendorfs de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação provisória e exame toxicológico definitivo (fls. 34 e 118/120).

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, MIKE DIORDAN JORDÃO COSTA e VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, guardavam e tinham em depósito 10 (dez) eppendorfs de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação provisória e exame toxicológico definitivo (fls. 34 e 118/120).

Consta, ainda, que, no dia anterior, no mesmo local, MIKE DIORDAN JORDÃO COSTA e VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, adquiriram e ocultaram, em provieto próprio, 02 (dois) aparelhos televisores da marca LG, pelo valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), os quais sabiam ser produtos de crime.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do acusado MIKE foi convertida em preventiva e a acusada VITÓRIA foi solta após concessão da liberdade provisória (fls. 74/76).

A denúncia foi recebida em 14 de março de 2021 (fls. 132/133), os réus foram regularmente citados (fls. 155 e 176), ambos apresentando defesa escrita às fls. 184/186.

Durante a instrução, foram tomadas as declarações da vítima e colhido o depoimento de 01 (uma) testemunha arrolada em comum, sobrevivendo, ao final, os interrogatórios dos acusados (fls. 238/239).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia (fls. 254/261).

Já a defesa dos réus MIKE e VITÓRIA requereu a absolvição de ambos do crime de receptação, vez que MIKE não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens e a ré VITÓRIA não participou da compra. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, aplicando-se o parágrafo 5º, deixando-se de aplicar a pena. Quanto ao crime de tráfico, requereu a absolvição da ré VITÓRIA, pela inexistência de provas de que ela tenha concorrido para a atividade ilícita de MIKE. Em caso de condenação, para o acusado MIKE, requereu seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, e para ambos a atenuante da menoridade penal relativa; aplicação da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06; a fixação do regime aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e o direito de recorrer em liberdade (fls. 266/282).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), e de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), ambos em concurso material.

Considerando que a presente ação penal apura mais de um delito, envolvendo os mesmos réus, passo a analisar separadamente os fatos, para sua melhor elucidação.

Tráfico de Drogas.

Quanto a esse delito, a ação é procedente para ambos os réus.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos

fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01); Recibo de entrega de Preso (fls. 02/03); Boletim de Ocorrência fls. 11/14; Notas de culpa (fls. 26/27); Depósito Judicial (fls. 102); Laudos Periciais (fls. 34, 118/120 e 158/160); Relatório Final (fls. 121/123); os depoimentos das testemunhas, as indigestas negativas apresentadas pela acusada VITÓRIA e a confissão apresentada pelo réu MIKE em ambas as fases da persecução penal.

Na fase policial, a acusada Vitória Rodrigues de Oliveira, relatou que os policiais militares entraram em sua residência e perguntaram se havia algo de ilícito.

Prontamente, informou que havia dois televisores que estavam em seu quarto, que seu esposo Mike havia comprado de um homem desconhecido. Afirmou que as drogas apreendidas pertenciam a Mike, que as vendia. Do dinheiro apreendido (R\$239,00), R\$ 100,00 era proveniente da venda de drogas e o restante foi sua mãe quem lhe deu. Disse que não tinha qualquer participação na venda das drogas, mas sabia que Mike traficava, para sustentar seu filho (fls. 07/08).

Como se viu, na fase policial, a acusada afirmou que sabia que MIKE comercializava drogas.

Já em juízo, a acusada Vitória passou a negar que tivesse conhecimento que seu esposo Mike comercializava de drogas, mas disse que a finalidade da droga apreendida era para uso de Mike e também para venda. Quanto ao dinheiro apreendido, disse que pertencia a Mike.

Diante dessas contradições, relacionadas a pontos de fundamental relevância para o deslinde da causa, não há como se dar credibilidade às versões apresentadas pela acusada, que restaram contraditórias e isoladas, se cotejadas às demais provas coligidas sob o crivo do contraditório, que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, como se verá doravante, tratando-se de mero expediente utilizado na tentativa de afastar a responsabilização penal por condutas efetivamente praticadas.

Por sua vez, o acusado Mike Diordan Jordão Costa, em ambas as fases da persecução penal, confessou a prática do tráfico, em razão das dificuldades financeiras. Disse que sua esposa Vitória sabia que ele comercializava drogas, mas não participava de nada. Disse que o valor apreendido era proveniente do tráfico. Confirmou ainda que a balança de precisão era utilizada para pesar drogas (fls. 09/10 e 238/239).

A confissão livre e espontânea prestada no processo, serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

De fato, no caso, a confissão do réu encontrou total respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Com efeito, a testemunha Marcelo Alberto dos Santos, policial militar, ouvido em ambas as fases, disse que recebeu uma denúncia anônima de que, numa residência situada no Bairro Portal da Pérola, um indivíduo chamado "Mike" seria um dos autores de um furto na cidade de Buritama/SP. No local foi recebido por uma moça, identificada como VITÓRIA. Pelo outro lado da casa, o Cabo Santos avistou um sujeito, pulando o muro, o qual foi abordado e identificado como Mike, o qual estava com 130 cápsulas "eppendorf" de cocaína dentro de uma mochila. Foram apreendidos também uma balança de precisão e aproximadamente 500 cápsulas "eppendorf" vazias. No interior do quarto, sobre uma cômoda havia o valor de R\$ 239,00 em dinheiro (notas e moedas), bem como mais quatro cápsulas "eppendorf" de cocaína e numa gaveta em meio as roupas de Vitória, mais seis cápsulas "eppendorf" de cocaína (fls. 02/03 e 238/239).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha José Roberto dos Santos, policial militar, ouvido na fase judicial (fls. 04/05).

Os relatos dos policiais evidenciam, portanto, que os réus incidiram na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente.

Aliás, o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor

na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar os acusados, ou em imputar falsamente a eles a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

A defesa, por sua vez, não trouxe aos autos elementos que evidenciassem interesse das testemunhas em imputar falsamente aos acusados a prática de conduta definida como crime.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, a perícia apontou que consistem realmente em "cocaína" (fls. 118/120).

Não se pode olvidar que foi apreendida balança de precisão na casa dos acusados, além de pinos vazios, o que só vem reforçar que ali se praticava o tráfico, haja vista que, como é cediço, apetrechos desse tipo são utilizadas para quantificação e preparo das porções que serão vendidas, o que foi confirmado pelo réu Mike. De outra parte, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo, guarde e tenha em depósito para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, os réus foram denunciados porque trazia consigo, guardavam e tinham em depósito a droga.

Assim, a quantidade de entorpecente apreendido, ou seja, 111,54 gramas de cocaína, conforme se constata dos laudos de fls. 34 e 118/120, as circunstâncias da abordagem dos réus; a forma de acondicionamento das drogas; a apreensão dos apetrechos (balança de precisão, além de tubos plásticos do tipo "eppendorf" vazios), e os depoimentos dos policiais, estão a caracterizar a traficância. Quanto ao valor apreendido, o réu MIKE confessou a prática do tráfico de drogas e que todo o dinheiro apreendido na residência é produto dessa atividade, afastando, pois, as versões trazidas pela corré sobre o numerário apreendido.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, os acusados traziam consigo, guardavam e tinham em depósito 111,54 gramas de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta dos réus encontram tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade. Neste ponto, não há como reconhecer eventual estado de necessidade, já que não vislumbro a presença do perigo atual, como exigido pelo artigo 24, caput, do Código Penal, anotando que os acusados não trouxeram qualquer prova do que foi alegado por eles. Afora isso, poderiam os réus ter realizado outras condutas lícitas que não o tráfico de drogas, para sustentar sua família.

Ressalto ainda que, apesar de o réu Mike ser usuário de droga, tal fato, por si só, não lhe impede de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. Se o réu é usuário há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas. Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário de drogas não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem.

Receptação.

Neste ponto, a ação também é procedente quanto aos dois acusados, porque as autorias e a materialidade do delito restaram comprovadas.

Nesse sentido temos: Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01); Recibo de entrega de Preso (fls. 02/03); Notas de culpa (fls. 26/27); Boletim de Ocorrência PM (fls. 103/107); Relatório Final (fls. 121/123); e as indigestas negativas apresentadas pelos acusados em ambas as fases da persecução penal.

Em ambas as fases, os acusados Vitória e Mike relataram que Mike comprou os dois televisores de um homem, de nome Eduardo, pelo valor de R\$ 500,00, alegando que pertenciam a mãe dele, que havia falecido. Não tinham conhecimento que os televisores eram produtos de furto. Não souberam dizer o nome completo ou endereço dessa pessoa que lhes vendeu os bens (fls. 07/08, 09/10 e 238/239).

Todavia, as negativas apresentadas pelos acusados não merecem credibilidade, pois estão totalmente contrárias às provas coligidas nos autos e isoladas de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariadas por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado por receptador experimentado, na tentativa de se furtarem da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

Com efeito, a vítima Leylson Bispo Montoro, ouvida na delegacia e em juízo, confirmou que, dentre os vários objetos furtados de sua residência, havia dois televisores. Sua vizinha lhe relatou que dois indivíduos tinham saído de um terreno baldio aos fundos de sua residência e partido sentido bairro Portal da Pérola.

Afirmou que recuperou os dois televisores (fls. 06 e 238/239)

Como se vê, a vítima confirmou a ocorrência do crime anterior (furto), bem como que recuperou os televisores furtados.

A testemunha Marcelo Alberto dos Santos, policial militar, ouvido em ambas as fases da persecução penal, afirmou que recebeu uma denúncia anônima de que, numa residência situada no Bairro Portal da Pérola, um indivíduo chamado "Mike", seria um dos autores de um furto na cidade de Buritama/SP. No local, foi recebido por uma moça, identificada como Vitória, onde foram encontrados dois televisores e três controles remotos. Questionado, Mike disse que comprou os dois televisores, pelo valor de R\$ 500,00, não sabendo dizer de quem comprou (fls. 02/03 e 238/239).

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha José Roberto dos Santos, policial militar, ouvido na fase judicial (fls. 04/05).

Os depoimentos dos policiais evidenciam que os réus incidiram na prática de receptação, demonstrando que tinham ciência da origem ilícita dos objetos, deixando evidenciado o dolo com que agiram naquela ocasião.

Reitero, aqui, os argumentos acima expostos sobre o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais.

A vítima confirmou a ocorrência do crime anterior (furto), além de ter dito com clareza que os bens encontrados na posse dos réus lhes pertencia.

O furto anterior também foi comprovado pelos boletins de ocorrência de fls. 103/107.

Não se pode olvidar que os bens foram encontrados na posse dos réus (vez que os objetos estavam na casa deles) e, em se tratando de receptação dolosa, caberiam a eles o ônus da prova da origem lícita dos bens apreendidos em suas posses. Em outras palavras, quando o bem subtraído é encontrado em poder do agente, esse fato gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.

Assim, é óbvio que os acusados sabiam da origem ilícita dos bens que foram apreendidos.

Consigno que, nos crimes de receptação, a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato. Em outros termos, a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode se extrair da própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolvem a infração. Sendo assim, o dolo específico constante do artigo 180, caput, do Código Penal, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da coisa, deve ser auferido por intermédio do exame de todas as circunstâncias que cercam o seu recebimento e o

exercício da posse propriamente dita, lembrando que, no caso, os réus pagaram R\$ 500,00 por dois televisores, comprando os bens de um desconhecido (cujo nome completo e endereço sequer soube informar no processo) e sem apresentação de qualquer nota fiscal.

Tudo isso confirma a presença do dolo e afasta a pretensão de desclassificação para receptação culposa.

Ressalto que o fato de a vítima ter conseguido recuperar os bens, não afasta a responsabilidade penal dos acusados.

Além da robusta prova oral colhida na instrução, há também indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios.

Diante desse quadro probatório, não há como se deixar de reconhecer que no dia, horário e local indicados na denúncia, os acusados VITÓRIA e MIKE adquiriram e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, dois televisores, que sabiam ser produtos de crimes.

As condutas dos acusados encontram tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 180, caput, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade dos agentes. Neste ponto, como já mencionado quanto ao crime de tráfico, não há como reconhecer eventual estado de necessidade, já que não vislumbro a presença do perigo atual, como exigido pelo artigo 24, caput, do Código Penal, ficando adotados aqui, como razão de decidir, os mesmos argumentos já expostos acima, para evitar repetição desnecessária.

Reconheço a ocorrência dos delitos e passo à aplicação das penas, separadamente.

Das penas.

Tráfico de Drogas.

Os acusados não ostentam maus antecedentes, no entanto, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução da considerável quantidade de droga no mercado (nada menos do que 111,54 gramas de cocaína), se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-lo com a sanção base mínima, tratando-o igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes.

Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das conseqüências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e conseqüências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve

apreensão de grande quantidade de droga" (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

"Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repressão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida" (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro - JUTACRIM 44/293).

"A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC - 687055624 - Rel. Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154)

PENA - Agravantes - Tráfico de entorpecentes - Associação - Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o "modus operandi" do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível "reformatio in pejus", a pena cominada na r. sentença deve prevalecer - Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Marco Antonio - 23.8.2007 - V.U. - Voto n. 6.277)

Portanto, levando em conta o dado elencado, no aspecto acima relatado (quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para cada réu.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da menoridade penal relativa (ambos os réus menores de 21 anos na época dos fatos), razão pela qual retorno as penas a seus patamares mínimos, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cada réu.

Não é caso de reconhecimento da atenuante da confissão para o réu Mike, porque ele alegou estado de necessidade, que é uma excludente de ilicitude, procurando eximir-se de sua responsabilidade penal, lembrando que o entendimento deste Juízo é no sentido de que a confissão espontânea a que alude o artigo 65 do Código Penal, como circunstância determinante de alguma redução de pena, é aquela sem ressalvas, sem desculpas para o gesto criminoso, a qual não restou configurada no caso. Não bastasse isso, ainda que essa atenuante fosse reconhecida, a pena não seria reduzida, porque já está fixada em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Não é caso de incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque restou demonstrado, por todos os elementos acima descritos, bem como pela apreensão de grande quantidade de droga (nada menos do que 111,54 gramas de cocaína), que os acusados se dedicavam à narcotraficância em escala expressiva, guardando grande quantidade de droga na residência apontada na denúncia, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicavam a atividade criminosa, fazendo do tráfico os seus meios de vida.

Neste sentido, já se decidiu:

" Sem incidência , porém, na última fase da dosagem, de retroativa redutora, por conta do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que, pese a primariedade e bons antecedentes, concretamente, a forma de embalagem da droga apreendida (cerca de sessenta e cinco invólucros), sua natureza (crack) e forma de ação desenvolvida - para fim de venda a indeterminado número de pessoas - antes de caracterizar eventual pequeno tráfico, traz indicações de fazer do fato modo de vida, exercício de atividade criminosa."

Em outros termos, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao

princípio da insignificância, poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte do acusado, já que realizava o tráfico em escala considerável, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, razão pela qual não faz jus à redução em questão.

Torno definitivas as penas em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cada um dos acusados.

Receptação.

Os réus não possuem maus antecedentes, além do que as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis para o crime de receptação.

Fixo, pois, a pena-base, em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada réu.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade penal relativa (ambos os réus), mas deixo de reduzir a pena, pois já fixada em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Não é o caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pelos mesmos motivos expostos acima (réu Mike alegou estado de necessidade).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Torno definitiva a pena do crime de receptação em 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, para cada réu.

Reconheço o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão somadas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal, resultando em 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a qual torno definitiva, para cada um dos réus.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), as penas devem ser cumpridas no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, quanto ao réu MIKE, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

O acusado MIKE deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

A acusada VITÓRIA poderá continuar a responder solta a este processo, pois assim permaneceu durante a instrução.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MIKE DIORDAN JORDÃO COSTA e VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, ao cumprimento, cada um, das penas de 06 (seis) anos de reclusão (resultado da soma das penas de 05 (cinco) anos de reclusão, referente ao crime de tráfico, e 01 ano de reclusão, no tocante ao crime de receptação), em regime inicial fechado, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, dando-os como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 180, caput, nos moldes do artigo 69 do Código Penal.

Consigno que o acusado MIKE ficou preso cautelarmente desde 09/02/2021 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detracção penal).

Deixo de substituir as penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contra-senso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugerir-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de

pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastasse todos os argumentos expostos nos votos supracitados, no caso concreto, a substituição não é possível, porque as penas aplicadas são superiores a quatro anos, além do que os réus traziam consigo e guardavam considerável quantidade de entorpecente para entrega a consumo de terceiros (nada menos do que 111,54 gramas de cocaína), o que demonstra que o benefício não seria recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime praticado.

O acusado MIKE deverá continuar a responder preso a este processo, eis que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme decisão proferida a fls. 74/76, cujos argumentos ficam aqui reiterados, como razão de decidir.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar do acusado MIKE, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos. Nesse aspecto, a ordem pública merece resguardo.

Recomende-se o réu MIKE na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela

Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A acusada VITÓRIA foi solta mediante liberdade provisória concedida na audiência de custódia e assim permaneceu durante a instrução, razão pela qual poderá continuar a responder a este processo em liberdade.

Quanto aos dois televisores apreendidos, já foram restituídos ao proprietário (fls. 17), nada mais havendo a ser deliberado a respeito.

Pela prova colhida nos autos, não há como se deixar de reconhecer que o dinheiro apreendido às fls. 15/16 (R\$239,00) é produto do tráfico de entorpecentes, razão pela qual, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº. 11.343/06 decreto o perdimento do dinheiro apreendido (depósito fls. 102).

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supradeterminado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Quanto aos objetos apreendidos (ependorffs, mochila e balança), apesar de serem instrumentos do tráfico de drogas praticado pelos acusados, diante da sua natureza, entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento do dinheiro (R\$ 239,00) e sobre a destruição dos objetos apreendidos, instruindo-se o ofício com as cópias.

Por fim, em relação aos demais bens apreendidos às fls. 15/16 (celular Motorola, Mouse, celular Samsung e Notebook Vaio), aguarde-se o trânsito em julgado da presente, retornando-se conclusos, oportunamente, para outras deliberações a respeito desses bens.

A incineração dos entorpecentes apreendidos já foi determinada e realizada a fls. 190/191, nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA